

1508758-88.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARISTIDES MARTINS NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 20 de abril de 2020, por volta das 08h30, na Alameda Dino Bueno, 100, Santa Cecília, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, ARISTIDES MARTINS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1508758-88.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508758-88.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARISTIDES MARTINS NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 20 de abril de 2020, por volta das 08h30, na Alameda Dino Bueno, 100, Santa Cecília, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, ARISTIDES MARTINS NETO, qualificado à fl. 11, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (uma)

porção de cocaína (0,1 g), 05 (cinco) porções de tetrahidrocannabinol (5,0 g) e 04 (quatro) porções de cocaína na forma de crack (4,1 g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 499,25 (quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) em espécie (BO de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação de fls. 27/30)", pelo que foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Após defesa preliminar, ratificou-se o recebimento do libelo.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a desclassificação da conduta para o delito de posse de entorpecentes para uso próprio, com base na prova dos autos, no que foi acompanhado pela Defesa.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra indícios diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A busca pessoal realizada, porém, é nula por vício de competência, e desde logo deixa-se assentando que este Juízo NÃO ESTÁ AFIRMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE GUARDAS CIVIS REALIZAREM PRISÃO EM FLAGRANTE, mas sim a ilegalidade de busca pessoal realizada por agentes não policiais.

De fato, há ilegalidade na apreensão das drogas, realizada por Guardas Civis Metropolitanos, a quem o artigo 144, § 8º., da Constituição Federal não outorga poder de polícia para investigar crimes nem para atuar no policiamento repressivo. Ora, no caso dos autos, houve uma desconfiança de que o réu pudessem ter algo ilícito consigo, pela forma como reagiu ao ver os guardas.

Sem que houvesse a certeza visual da posse de drogas, realizou-se a abordagem do acusado, submetendo-o a revista pessoal, oportunidade em que se encontraram em suas vestes as drogas e o dinheiro apreendidos.

Tal diligência é ilícita, por manifesto desvio de função.

A Guarda Civil não tem competência e nem autoridade para realizar busca pessoal em via pública, porque desconfia da atitude de um passante.

Busca pessoal é ato de investigação policial, disciplinado nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, e como tal está reservado às polícias a quem a Constituição Federal outorgou tal competência.

Se a qualquer cidadão é outorgado o direito de prender indivíduo em situação de flagrância, parece igualmente evidente que somente as autoridades competentes é que podem submeter um suspeito a busca pessoal. Ninguém admitiria ser revistado por qualquer do povo, e aliás admitir-se tal possibilidade equivaleria a degenerar a autoridade estatal e a pôr em risco a própria convivência em sociedade.

Ora, para fins de busca pessoal, um guarda civil tem a mesma competência legal que um cidadão qualquer, ou seja, nenhuma.

Não se está aqui a tratar nem de situação de evidente flagrância (pois ninguém viu o réu manuseando drogas) e nem de mera revista preventiva (por exemplo, no acesso a grande evento) em que, fortuitamente, encontrou-se algo ilícito. Houve a prática de ato típico de polícia (busca pessoal fundada em suspeita) por agente público absolutamente incompetente para tanto, desbordando das funções que a Constituição Federal permitiu às guardas municipais.

Nesse sentido, cito precedentes:

Por expressa previsão constitucional, às forças policiais civil e federal fora reservada atribuição para a investigação de fatos delituosos, ao passo que à guarda municipal não fora prevista qualquer atuação em matéria de segurança pública. E, enquanto agentes administrativos, regidos pelo princípio da legalidade, só podendo atuar aonde a lei autoriza, essa falta de previsão implica verdadeira vedação de agir.

Guardas civis municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação

pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo, atividade, repita-se à exaustão, por expressão previsão constitucional, exclusiva das forças policiais. Nos termos da redação do §8º do artigo 144 da Constituição da República, incumbe aos guardas municipais somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo disposto no caput do artigo 144, a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares.

(...)

Se é evidente a invalidade do comportamento dos guardas civis que, em contrariedade à Constituição, estavam a investigar e à busca de ilícitos criminais, são ilícitas, por derivação, as provas obtidas. Isto porque tudo fora coligido como fruto de diligência realizada por órgão administrativo sem atribuição constitucional e legal para a prática de atos concernentes à segurança pública. (TJSP - Apelação nº 0001468-60.2016.8.26.0544 - Franco da Rocha - rel. Márcio Bártoli - 1ª. Câmara Criminal - j. 23.04.2018)

Merece ainda seja trazido como fundamento o v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, na RevCrim 0034551-84.2015.8.26.0000 (6º Grupo Criminal, rel. Vico Mañas, j. 07.06.2007, M.V), pela riqueza de argumentos e citações colmatados, inclusive com menção a precedente do C. Órgão Especial do mesmo Tribunal, que declarou inconstitucional dispositivo de lei municipal que pretendeu conferir à Guarda Civil Metropolitana atribuições típicas de polícia:

Ora, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal atribui aos guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Atividades de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo, constituem função das polícias civil e militar.

Nem se diga que, regulamentando a norma constitucional, a Lei 13.022/14 prevê como "competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais", "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social", "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário" (art. 5º, IV e XIV). Parece claro que tais disposições não autorizam a guarda municipal a efetuar diligências para apurar suspeitas de tráfico, permanecendo tais atividades privativas da polícia.

Cumpram ainda observar que a Lei 13.022/14 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5156, em que se questiona a possibilidade de atribuir às guardas municipais funções de segurança pública. E, em seu parecer, o Procurador-geral da República opina que "não compete a guarda municipal o exercício, direto ou indireto, de atividades próprias à segurança (...). As guardas só podem existir se destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Não lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil, consoante prescrevem os §§ 4º e 5º, do susotranscrito art. 144 da Carta Federal".

Esse também o entendimento adotado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal ao declarar a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 1º da Lei nº 13.866/04, do Município de São Paulo, que disciplina a atuação da Guarda Civil Metropolitana: "se, por um lado, a Constituição Federal abre possibilidade aos Municípios de constituírem 'guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei' (art. 144, § 8º - regra repetida pelo art. 147 da Constituição Estadual), por outro, atribui o exercício da segurança pública a outros órgãos, descritos no mesmo artigo, nos seus incisos. Esses órgãos são as chamadas polícias que, no âmbito estadual, são a polícia militar, que atua preventivamente, e a polícia civil, de caráter repressivo. Releva notar que a descrição do 'caput' do art. 144 não deixa dúvidas: a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesse diapasão, ao se examinar o inciso I do artigo 1º da legislação municipal,

percebe-se nítido o conflito com o mandamento constitucional. Isso porque traz como atribuição da Guarda Civil Metropolitana o exercício de policiamento preventivo e comunitário, expressão que indica a atividade de segurança pública e que somente pode ser exercida pelos órgãos já mencionados. (...) são atividades, pois, típicas de segurança pública, que se inserem no âmbito exclusivo do Estado, com suas polícias. A limitação da competência das guardas municipais se dá, assim, pelo cotejo entre os parágrafos do art. 144 e também com o seu 'caput'" (Adinº 154.743-0/0-00, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. em 10.12.2008).

(...)

Também merece destaque o parecer do d. Procurador de Justiça oficiante, Luiz Antonio Guimarães Marrey, para quem o limite constitucional de ação das guardas municipais está claramente estabelecido, ainda que o art. 144, § 8º, da CF faça parte do capítulo "Da Segurança Pública": "o exercício do poder de polícia municipal, nas atividades que lhe são próprias, não se confunde com a atividade de polícia judiciária ou de manutenção da ordem pública, deferidas aos Estados e que não podem ser delegadas. Dessa forma é ilegítima a atividade de investigar e de fazer buscas pessoais ou em veículos por parte de integrantes da Guarda Municipal, em atividade estranha à sua atribuição constitucional. Aceitar-se conclusão contrária significaria admitir que cidadãos comuns devem suportar buscas feitas a esmo por funcionários públicos municipais que não exercem a função policial (...). Se há suspeita de crime, como regra, devem os guardas chamar a polícia e dar as informações pertinentes que permitam a ação policial. Claro que poderão agir quando houver flagrante delito visível, mas o farão na condição de pessoas do povo, como por exemplo um roubo à mão armada que esteja em curso ou em situação de flagrância ou mesmo o tráfico de drogas realizado de maneira explícita. No entanto, ninguém é obrigado a se submeter a revista feita por iniciativa de qualquer pessoa do povo". Em artigo, o ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo também ponderou que, "quando a Guarda Municipal age escancaradamente como polícia, está aberta a porta para a repetição de episódios de violência e criminalidade. Não é incomum ver rondas ostensivas de guardas civis, imitando a polícia. Assim, é necessário que autoridades policiais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário atuem para coibir a ilegalidade, reconduzindo a atividade das Guardas Municipais aos limites constitucionais e legais. O que não se pode aceitar é que, em nome da necessidade de segurança pública, o abuso e a ilegalidade sejam permitidos, por vezes com graves consequências. A lei autoriza o uso da força de maneira legítima e estrita, mas o Estado de Direito deve valer para todos, exigindo que a violência e a ilegalidade sejam coibidas e punidas, venham elas de criminosos comuns ou de agentes públicos (Folha de São Paulo, "Guarda Municipal não é polícia", publicado em 05.07.2016, disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/07/1788484-guarda-municipal-nao-epolicia.shtml>)"

Destarte, ante a desconfiança que a atitude do réu causou aos Guardas Civis, cabia-lhes comunicar tal fato a autoridades policiais para que estas, legitimadas a tanto, realizassem a diligência tipicamente investigativa de busca pessoal. Praticado o ato por agente público a quem o ordenamento jurídico não outorga competência para tanto, não há como admitir a lícitude da apreensão dos entorpecentes.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública e ABSOLVO o réu ARISTIDES MARTINS NETO da imputação irrogada pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino, ao trânsito em julgado, a destruição das restantes amostras dos entorpecentes apreendidos.

O dinheiro apreendido, pertencente ao réu, deverá ser-lhe restituído. Não reclamado em 90 dias após o trânsito em julgado, será revertido ao Fundo Penitenciário, por analogia ao artigo 123, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 31 de março de 2022.